

1500189-52.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2016167/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22517091 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 238/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2016167 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500189-52.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-52.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2016167/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22517091 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 238/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2016167 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEMILSON DOS SANTOS SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Demilson dos Santos Santana, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 12h24, na Viela Arco Verde, 111, Vila Machado, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, (i) 98,37g de tetrahidrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, acondicionado em 56 porções, (ii) 49,08g de cocaína, dividida em 104 invólucros, e (iii) 20,75g de cocaína em forma de "crack", fracionada em 85

unidades, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Laudo prévio de constatação da droga às fls. 06/11.

A denúncia foi recebida à fl. 68, em 27 de janeiro de 2022.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 76/77.

Regularmente citado (fl. 86), o Réu apresentou resposta à acusação à fl. 90 e à fls. 126/130.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 104/106.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas William da Silva Dias, Robson Rosa da Silva e Erivânia dos Santos Silva. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 165/171 e 177/184, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas. Anoto que a preliminar suscitada pela Defesa restou decidida às fls. 194/195.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/15, pelo auto de exibição/apreensão de fl. 04, pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 18/20 e fls. 104/106, respectivamente.

A autoria do delito, por sua vez, é incontroversa, estando comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha William da Silva Dias, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe, quando, ao entrarem em via pública, avistaram o Réu, que, ao perceber a presença dos agentes públicos, dispensou sacola próximo a um gramado. Em razão da atitude suspeita, realizaram a sua abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, ao passo que, no interior da sacola dispensada, havia drogas diversas (cocaína, maconha e crack). O acusado estava parado na via pública municipal quando foi avistado. Na região, há escolas municipais e estaduais objeto de patrulhamento da guarda. Não sabe se o Réu tem apelido, mas, pelo que se recorda, ele informou que tinha um irmão gêmeo. O Réu esboçou reação de que não queria ser preso: tentou se desvencilhar da algema, mas não fugiu nem praticou ato de violência. Não havia mais ninguém no local. As drogas de fato estavam na posse do acusado, porque viram ele tentando se desfazer dela.

No mesmo sentido, a testemunha Robson Rosa da Silva relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu parceiro de equipe, quando, ao adentrarem via pública conhecida pela prática de venda de entorpecentes, avistaram o Réu. Ato contínuo, o acusado tentou se desvencilhar de uma sacola em um mato e, após, se manteve inerte, tentando disfarçar. Acredita que ele pensou que o declarante e seu companheiro de equipe não viram ele jogando a sacola na grama, próximo ao local em que estava. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Réu. Na sacola, contudo, havia diversos entorpecentes, de natureza variada (crack, cocaína e maconha). Não houve oposição de resistência. Não sabe se o acusado é conhecido por apelido e não se lembra da quantidade da droga apreendida. No local em que avistaram o Réu, só havia ele. Na via pública, um pouco mais distante, havia outras pessoas, inclusive, mulheres e crianças de passagem. A sacola apreendida foi a dispensada pelo Réu, então, pode afirmar que pertencia a ele.

Com efeito, a prova oral colhida, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamenta o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando

corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Assim, o depoimento dos guardas municipais só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os guardas municipais abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista esse se encontrava em local conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes e, ao avistar os agentes públicos, tentou imediatamente se desfazer de sacola que trazia consigo -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se que os agentes públicos e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados, e que os guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Por outro lado, as declarações da testemunha de defesa e do Réu não foram suficientes para afastar o conjunto probatório desfavorável a ele.

A testemunha Erivânia dos Santos Silva contou que conhece o Réu, mas não sabe de envolvimento dele com confusão ou outros crimes. Possui convívio com a família dele também, que frequenta a Igreja.

Em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, havia saído com seus amigos para conversar e ficaram próximos de sua casa. Havia uma torneira na via pública, onde parou para beber água. Quando se virou, viu que seus amigos estavam sendo abordados. Ato contínuo, também foi revistado. Afastaram seus amigos e falaram que iam forjá-lo na posse das drogas. Quando estava descendo a rua, o guarda William o algemou. Disse que o Réu estava sendo procurado e, por isso, ia ser levado à delegacia. Acabou se sentindo coagido porque foi levado sozinho à delegacia. Não se lembra de ter efetuado depoimento em delegacia. Não conhece o delegado de polícia nem o escrivão e não confessou os fatos em delegacia. Estava a uns cinco metros da porta da sua casa quando foi abordado. Não chegou a ver a sacola com drogas no local da abordagem. Acha que os amigos não podem depor em seu favor, porque não tem mais contato com eles.

Nota-se que a versão apresentada pelo Réu é fantasiosa e não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso da instrução, bem como na realidade fática. Isto, pois não é crível que os agentes públicos o teriam imputado a posse de entorpecentes à revelia da lei e sem qualquer motivo aparente.

Ademais, ambos os guardas municipais foram uníssonos em apontar que o acusado estava com sacola com entorpecentes em suas mãos e tentou se desfazer dela imediatamente, inexistindo em seus relatos quaisquer contradições que permitam inferir flagrante forjado.

Não bastasse, em sede policial (fl. 12), o acusado admitiu integralmente a prática delitiva, aduzindo que “estava sem serviço, ficou envergonhado porque seus irmãos e seu pai trabalham, então decidiu ganhar algum dinheiro traficando drogas; (...) foi até um conhecido ponto de venda de drogas, pediu uma oportunidade para assumir um turno no ponto de vendas e, no dia seguinte, pegou algumas 'malas' (sacolas contendo 130 ou 140 porções individuais de drogas) e começou a vender as porções naquele ponto”.

Deste modo, inevitável concluir pela procedência da ação penal, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

No que tange à licitude da prova, em que pese guardas municipais não possuírem atribuições constitucionais para realizar investigação criminal, qualquer pessoa do povo pode realizar prisão em flagrante delito, consoante art. 301, CPP. No caso, os agentes públicos atuaram em local público, em situação que não exigia a expedição de mandado ou aprofundamento das investigações por parte dos órgãos competentes. Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação. Impossibilidade. Paciente e corréus que estavam em atitude suspeita, transportando entorpecentes. Situação de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Precedentes Ordem denegada”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2065756-68.2013.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro: 11/08/2014).

“Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar. Alegada nulidade da prova colhida pela guarda municipal. Inexistência de ilicitude da prova. Guarda municipal prevista no art. 144, § 8º, da CF, e regulamentada pela Lei 13.022/14. Expressa previsão de prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado de polícia. Outrossim, por expressa previsão do art. 301 do CPP, cabe a qualquer do povo prender quem se encontre em flagrante delito. Seria um contrassenso autorizar qualquer cidadão a realizar a prisão em flagrante e impedir que a guarda municipal o fizesse. Prova lícita. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação quanto à dinâmica dos fatos. Réu confesso. Penas. Redução. Necessidade. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1501482-56.2020.8.26.0567; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021).

Logo, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a atuação dos agentes públicos ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não extrapolando os limites constitucionais de sua atuação.

No que se refere à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto parte se encontrava pulverizada em pequenas porções (consoante auto de exibição de fl. 04, em mais de duzentas e quarenta unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros.

Deste modo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06), ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, inexistem provas nos autos que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaco que a quantidade de droga (196,17g líquidos - fls. 07/08) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da

já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Logo, estabeleço como pena-base 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide ao caso a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), uma vez que o Réu assumiu integralmente a prática delitiva em delegacia. Entretanto, por já se encontrar a pena no mínimo legal, deixo de efetuar a sua redução - inteligência da Súmula nº 231, STJ.

Apesar de o delito ter sido praticado durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 (Covid-19), deixo de aplicar a agravante prevista no art. 61, II, alínea j, CP, por ausência de correlação com o fato. A existência da pandemia foi irrelevante para influir no dolo do agente, nas circunstâncias fáticas e na finalidade da infração.

Em terceira fase, viável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista o preenchimento dos requisitos mínimos, em especial, a primariedade do agente e a existência de bons antecedentes (certidão de fls. 76/77), bem como a ausência de provas de que se dedica exclusivamente às atividades de tráfico ou integraria organização criminosa.

Apesar de o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispor que a reincidência, os maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas são empecilhos à incidência da causa de diminuição de pena - sendo possível a compreensão de que, diferentemente das duas primeiras, a dedicação ao tráfico não requer a existência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao apurado nestes autos -, entendo ser necessário que haja, ao menos, sentença condenatória proferida em outro processo ou a verificação de situações evidentes, tais quais diversas prisões em flagrante repetidas em curto espaço de tempo, de modo a impedir a incidência da minorante em questão.

Como nos autos do processo nº 0006152-28.2018.8.26.0198 não houve condenação do Réu nem em primeira instância e não há provas nos autos que comprovem prisões reiteradas anteriormente aos fatos em questão, não é possível aferir, com algum grau de certeza e à luz da cláusula do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB), que este, de fato, se dedica à prática de atividades ilícitas.

Em outras palavras, inexistindo sequer condenação em primeiro grau de jurisdição, a presunção de não culpabilidade do acusado permanece hígida, não sendo mitigada pela simples existência de inquérito ou processo judicial em curso. Ademais, caso seja afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343 em razão da existência de ação penal em curso e o Réu venha a ser nessa inocentado ulteriormente, a fundamentação desta sentença terá se baseado em fato não reconhecido pelo próprio Poder Judiciário, o que importaria em contradição na prestação jurisdicional.

Logo, ante a ausência de ao menos sentença condenatória em tal processo - com vistas a mitigar a presunção de inocência do Réu quanto ao envolvimento em atividade reiterada de tráfico -, inviável acolher o pedido de afastamento de causa minorante da pena nesta decisão, com base na existência de ação penal em curso, cuja instrução sequer se encontra finalizada.

Sendo assim, reduzo a pena em 1/3, diante da quantidade da droga e das circunstâncias da prisão do agente. Deixo de efetuar a redução em seu máximo em razão da natureza variada dos entorpecentes apreendidos e excessiva pulverização (em mais de duzentos invólucros).

Fixo, portanto, a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime aberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP.

Considerando que o acusado preenche os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes (i) na prestação de serviços à comunidade e (ii) em prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, nos

termos dos artigos 45, § 1º, 46, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade ocorrerá pelo período fixado para cumprimento da pena corpórea, sendo facultado ao condenado cumprir em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena privativa (art. 44, § 4º, CP), em entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, observando-se, contudo, eventual suspensão em decorrência da fase do plano São Paulo relativo à pandemia Covid-19. A prestação pecuniária também será prestada a entidade indicada pelo Juízo da Execução.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Demilson dos Santos Santana como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, estabelecidos no valor mínimo legal, atualizados desde a prática delitiva, mediante a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes acima fixados.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP) à luz do princípio da proporcionalidade e homogeneidade das penas, tendo em vista o quantum de pena aplicado, o seu respectivo regime inicial aberto, e a substituição por restritivas de direito. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Franco da Rocha, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA